

1500268-89.2021.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... das drogas, de anotações típicas de tráfico e de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais), valor oriundo do tráfico ilícito."

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 14/17), o auto de constatação preliminar de substância entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500268-89.2021.8.26.0633 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 11/03/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-89.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME SOARES MUNHOZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

GUILHERME SOARES MUNHOZ, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 61, inciso II, "j" (calamidade pública), do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados na introitoal de fls. 01/05, a saber:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de setembro de 2021, em ocasião de calamidade pública (COVID-19), por volta das 17h24min, Rua Mariana dos Santos, 14, Guapurá, Oásis, nesta cidade e comarca de Itanhaém, Guilherme Soares Munhoz, menor de 21 anos, qualificado à fls. 04/05, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, 16 (dezesseis) porções de cocaína, 4 (quatro) porções de haxixe, 45 (quarenta e cinco) porções de cannabis sativa L e 22 (vinte e duas) porções de skunk, cf. auto de constatação preliminar de fl. 20, tudo

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que o denunciado trazia consigo os entorpecentes acima descritos, dentro de uma sacola plástica preta e, ao perceber a aproximação de policiais militares, a escondeu rapidamente em um abrigo de relógio de luz. Ato contínuo, o denunciado tentou evadir, correndo em direção ao matagal, contudo, foi alcançado e preso em flagrante, seguindo-se a apreensão das drogas, de anotações típicas de tráfico e de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais), valor oriundo do tráfico ilícito.”

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 14/17), o auto de constatação preliminar de substância entorpecente apreendida (fl. 25), o auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), a nota de culpa (fl. 38) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 103/104). Ulteriormente, foi anexado aos autos o laudo toxicológico (fls. 187/190).

Dispensada a realização da audiência de custódia, ex vi do art. 8º da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, concedeu-se ao acusado liberdade provisória (art.310, parágrafo único do CPP), mediante fiança (fls. 88/90). Novo valor arbitrado (fl. 142), em razão da alegação de ausência de condição financeira. Tendo em vista que o réu deu-se inerte, às fls. 154/155, decretou-se sua prisão preventiva, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública. Mandado de prisão expedido às fls. 156/157.

À fls. 172/173 determinou-se a notificação do acusado para fins de apresentação da defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. Notificado (fl. 174), apresentou-a às fls. 205/207, por intermédio de seu defensor dativo. Por estar em termos, foi de exordial devidamente recebida, designando-se audiência de instrução e julgamento (fls. 231/233). Foi juntado ao feito o comprovante de depósito judicial do valor apreendido (fl. 146).

Às fls. 213/216, foi requerida pela defesa a dispensa da fiança, bem como a revogação do decreto da prisão preventiva em face do acusado Guilherme, considerando a sua vulnerabilidade econômica, nos termos do artigo 350, do Código de Processo Penal, o que foi acolhido à fl. 258. Às fls. 262/263 foi expedido o contramandado de prisão.

Na solenidade, abertos os trabalhos, ressaltou-se que o réu seria interrogado após a inquirição das testemunhas arroladas, seguindo a mesma sistemática do procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Na sequência, foi dispensada a oitiva das testemunhas Gabriel e Kleber, seguindo-se o interrogatório do réu. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. A acusação, em linhas gerais, propugnou pela integral procedência da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do réu, sob a égide da anêmia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Guilherme Soares Munhoz nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, “j” (calamidade pública), do Código Penal.

A materialidade da narcotraficância encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de constatação prévia de entorpecente (fl. 25), do auto de exibição e apreensão (fls. 26/27) e, principalmente, pelo laudo toxicológico de fls. 187/190, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de 4,4g de cocaína, 3,2g de maconha, 202,1g de maconha e 22,3g de

maconha. A autoria do acusado, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório realizado na fase indiciária (fls. 09/10), disse que, por estar precisando de dinheiro, começou a vender drogas. Conversou com um rapaz que estava reativando uma "loja" e lá passou a trabalhar. Na tarde dos fatos, depois que o "recolhe" pegou parte do dinheiro, a Polícia Militar chegou, átimo em que tentou esconder a droga e fugir para o matagal, todavia sem êxito. Já estava trabalhando há dois dias seguidos, porém auferiu apenas R\$50,00. As anotações na folha que estava em seu poder não foram feitas por si, de toda forma, referiam-se à drogas, tratando-se "K2" de maconha dixavada, "avc" de cocaína à vácuo, "PG" de pino grande, "piquina" a cocaína pequena, "pura30" a cocaína pura de R\$30, "esk20" skunk de R\$20, "esk10" skunk de R\$10, "m20" de maconha de 20, "m5" de maconha de R\$5, e "m10" de maconha de R\$10. Em Juízo, na essência, confessou os fatos, nos termos da peça incoativa.

É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparada em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme art. 197 do Código de Processo Penal,

"o valor da confissão se aferira pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância."

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas.

O policial militar Gabriel, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 07), aclarou que estava realizando patrulhamento de rotina pelo bairro Guapurá junto do CbPM Kleber, quando um indivíduo percebeu a aproximação da viatura e tentou esconder uma sacola plástica preta em um abrigo de relógio de luz, na altura do nº14, da Rua Mariana dos Santos. Em seguida, o indivíduo correu em direção ao matagal. Afirmou que, juntamente de seu parceiro, desembarcaram da viatura e conseguiram acompanhá-lo. Após, retornaram com o réu ao local onde a sacola fora escondida e encontraram, em seu interior, diversas porções de cocaína, haxixe, maconha e skunk. O indivíduo foi identificado como sendo Guilherme Soares Munhoz. Em poder dele também foram encontrados R\$52,00 em espécie, uma folha de papel com manuscritos que aparentam estar relacionados à contabilidade do tráfico e um telefone celular Motorola. Questionado sobre a traficância, Guilherme disse que foi demitido do serviço e estava no segundo dia vendendo drogas para "levantar um dinheiro". Diante de tais fatos, foi dada voz de prisão a Guilherme, o qual foi conduzido para o plantão com as drogas, dinheiro e os demais objetos.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Kleber, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 08).

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, lembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais

testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Em outras palavras, segundo os policiais militares, na data dos fatos encontravam-se na Rua Mariana dos Santos, quando se depararam com um indivíduo em atividade suspeita. Ao abordá-lo, lograram encontrar, em poder do abordado, uma certa quantidade de entorpecentes, bem como dinheiro em espécie.

Estas são as provas. Diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação de tráfico que é ofertada ao acusado. É que a quantidade de droga encontrada (4,4g de cocaína, 3,2g de maconha, 202,1g de maconha e 22,3g de maconha), e as circunstâncias que envolvem o caso (a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, o dinheiro encontrado com o réu e uma folha de papel com manuscritos que aparentam estarem relacionados à contabilidade do tráfico), transparecem a finalidade comercial própria do tipo penal.

Observe-se ainda que os entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adrede preparados para venda, e que a abordagem fora realizada após a atitude suspeita esboçada pelo acusado. Veja-se que os depoimentos prestados pelos policiais mostraram-se harmônicos, incluindo neles a confissão do réu na abordagem, sendo, ainda, secundados pela apreensão de entorpecentes.

Todo o contexto da situação flagrancial não deixa dúvidas acerca da conduta ilícita cometida pelo acusado. De resto, não se pode imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar um desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros.

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

"o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo" (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

E ainda:

"considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004).

Em resumo, encontra-se, pois, o acusado incurso nas sanções artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DA PERDA DOS BENS:

Pela legislação em vigor, são três os tipos de bens que podem ser apreendidos: a) produtos do crime (art. 60): vantagem direta obtida com a prática criminosa. Ex: o dinheiro recebido com a venda da droga; b) proveito auferido (art. 60): é a vantagem indireta, conseguida a partir do produto, v.g., um carro comprado com a venda da droga; c) veículos, embarcações, aeronaves, maquinários, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática de crimes previstos na Lei (art. 62).

Ademais, acentua a doutrina mais judiciosa que para a decretação da perda dos bens e valores apreendidos, mostra-se necessária a demonstração do nexo etiológico a os unir com o crime apurado.

Pois bem, no caso dos autos, tenho de ser o caso de ser determinar o perdimento, do valor apreendido de R\$ 52,00 reais (fl. 146), pois o contexto em que fora localizado deixa evidente, portanto, que o lucro foi adquirido proveniente da traficância, tratando-se, portanto, de proveito auferido.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em ser desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardando em âmbito constitucional. Vale dizer,

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado"(STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09)

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências do crime foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão.

Presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal (calamidade pública), exaspero a pena em 1/6. Conforme bem enfatizado pelo Exmo Des. Edison Brandão, nos autos do julgamento da apelação n. 1509419-67.2020.8.26.0228, "de se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência." Presente a atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, "d", do CP, e da menoridade, ex vi no inc. I do art. 65 do Código Penal, atenuo a pena até seu mínimo legal.

Ausentes quaisquer causas de aumento. Presente, por outro lado, a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. E isso porque, além de se tratar de um direito subjetivo, verifica-se que o acusado é primário, portador de bons antecedentes. Embora efetivamente responda o acusado por outros feitos, o Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Assim, o mesmo raciocínio deve balizar a análise da aplicação do redutor em questão. Portanto, fica então operada a diminuição na metade, dada à nocividade da droga. A este respeito, observo que:

"o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da nova Lei de Drogas" (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 02 anos e 06 meses de reclusão.

Considerando que Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), deve o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, não podendo fundamentar a fixação do regime inicialmente fechado unicamente em relação à hediondez do delito de tráfico de drogas.

A tese restou assim ementada:

“É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” (ARE 935.967 AgR; Rel. Min. Edson Fachin; Primeira Turma; J.:15.03.2016)

Desse modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Vale ressaltar que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do §3º do art. 33, c.c art. 59 do Código Penal.

Na espécie, a pena privativa de liberdade, a despeito da primariedade do réu, deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada à diversidade e nocividade da droga.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do artigo 44 do Código Penal.

Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos arts. 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

“remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.” E isso por se entender que “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material”.

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo

a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

No caso, em vista da primariedade do acusado e do montante de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser substituída por uma pena restritiva de direito (art. 44, §2º, do CP), consistente prestação de serviços à comunidade, na razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, conforme o disposto no §3º do art. 46.

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (art. 77, inc. III, do CP).

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado GUILHERME SOARES MUNHOZ, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente semiaberto. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c §4º do mesmo preceito.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada hipossuficiência denotada.

Substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por uma pena restritiva de direito (art. 44, §2º, do CP) consistente na prestação de serviços à comunidade, na razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, conforme o disposto no §3º do art. 46.

Por ter sido condenado por crime de que se livra solta, em virtude da substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direito e, principalmente, por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, poderá o acusado recorrer em liberdade, conforme art. 387, §1º, do mesmo diploma, se por outro não estiver preso.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB – Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Decreto a perda em favor de entidade beneficente cadastrada neste Juízo do dinheiro apreendido (vide fl. 146, R\$ 52,00 reais).

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
2. Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal;
3. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da 7.210/84.
4. Transfira-se para entidade beneficente o dinheiro apreendido (fl. 146, R\$ 52,00 reais).

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA